

次の【会話】は、学生AとBによる、おとり捜査（捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働き掛け、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙する捜査方法をいう。）に関する議論である。この【会話】中の①から⑥までの（ ）内に後記アからクまでの【記述】の中からそれぞれ最も適切なものを選んで当てはめた場合、いずれの（ ）内にも入らない【記述】の組合せは、後記1から5までのうちどれか。なお、同じ【記述】は1回しか用いてはならない。

【会 話】

学生A. 私は、おとり捜査は、①から、「強制の処分」に当たり、法律に特別の定めがない以上、許されないと思うわ。

学生B. 「強制の処分」に関する最高裁判所の判例の考え方を前提とすれば、おとり捜査は、②から、「強制の処分」には当たらないと考えるべきだよ。

学生A. 百歩譲って任意捜査だとしても、おとり捜査は、本来犯罪を防止すべき捜査機関が詐術的手段を用いて相手方に犯罪を実行させこれを検挙するものだから、③という観点からは、おとり捜査を行う必要性や相当性が認められることが、おとり捜査が許されるための要件と考えるべきでしょうね。

学生B. 必要性や相当性の要件については、おとり捜査が、④という観点から考えるべきだと思う。このように考えることによって、第三者が被害者となる殺人や窃盗等についてのおとり捜査が原則として適法とされないことの説明が容易になるのではないかな。

学生A. ところで、⑤から、おとり捜査は、例えば、被疑者が既に大麻を所持しているという嫌疑があって、当該所持事犯の捜査の方法として行われるときに限って許されるべきよ。

学生B. ⑥から、おとり捜査が許されるのは、既に犯罪が行われている場合に限られないと考えるべきだよ。

【記 述】

ア. 将来発生する高度の蓋然性がある犯罪について、その検挙や証拠収集を目的として捜査を行うことも許される

イ. いわゆる機会提供型であれば許されるが、いわゆる犯意誘発型は許されない

ウ. 捜査の公正さや廉潔性に問題があり得る

エ. その相手方の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えるものではない

オ. 捜査機関等が相手方への働き掛けによって犯罪という法益侵害又はその危険を惹起するものである

カ. 刑事訴訟法の捜査は、既に行われたか又は現に行われつつある犯罪について行われるものである

キ. 捜査の対象となっている犯罪の嫌疑の程度、その重大性、おとり捜査の相手方の犯罪への関与の程度、捜査の困難性等を総合考慮して判断される

ク. 国家の干渉を受けることなく独自に意思決定をする自由を実質的に侵害する行為である

1. ア ク 2. イ エ 3. ウ オ 4. カ ウ 5. キ イ

№5	おとり捜査	正答率
H18-27	正解 5	74%

本問は、最判平 16.7.12（百選 11 事件）を題材にしたものである。

（ ）には順に、①=ク、②=エ、③=ウ、④=オ、⑤=カ、⑥=アが入る。よって、（ ）に入らない記述はイとキであり、したがって、正解は肢 5 となる。

完成全文

- 学生 A. 私は、おとり捜査は、(① ク、国家の干渉を受けることなく独自に意思決定をする自由を実質的に侵害する行為である) から、「強制的処分」に当たり、法律に特別の定めがない以上、許されないとと思うわ。
- 学生 B. 「強制的処分」に関する最高裁判所の判例の考え方を前提とすれば、おとり捜査は、(② エ、その相手方の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えるものではない) から、「強制的処分」には当たらないと考えるべきだよ。
- 学生 A. 百歩譲って任意捜査だとしても、おとり捜査は、本来犯罪を防止すべき捜査機関が審判的手段を用いて相手方に犯罪を実行させこれを検挙するものだから、(③ ウ、捜査の公正さや廉潔性に問題があり得る) という観点からは、おとり捜査を行う必要性や相当性が認められることが、おとり捜査が許されるための要件と考えるべきでしょうね。
- 学生 B. 必要性や相当性の要件については、おとり捜査が、(④ オ、捜査機関等が相手方への働き掛けによって犯罪という法益侵害又はその危険を惹起するものである) という観点から考えるべきだと思う。このように考えることによって、第三者が被害者となる殺人や窃盗等についてのおとり捜査が原則として適法とされないことの説明が容易になるのではないかな。
- 学生 A. ところで、(⑤ カ、刑事訴訟法の捜査は、既に行われたか又は現に行われつつある犯罪について行われるものである) から、おとり捜査は、例えば、被疑者が既に大麻を所持しているという嫌疑があって、当該所持事犯の捜査の方法として行われるときに限って許されるべきよ。
- 学生 B. (⑥ ア、将来発生する高度の蓋然性がある犯罪について、その検挙や証拠収集を目的として捜査を行うことも許される) から、おとり捜査が許されるのは、既に犯罪が行われている場合に限りえないと考えるべきだよ。

① ク

続く学生 B が判例をもって学生 A の本発言に反駁していること、及び学生 B はおとり捜査は「強制的処分」にあたらないとしているのに対し、学生 A はおとり捜査は「強制的処分」にあたるとしていることから、学生 A の本発言は判例に依拠したものではないこと、並びに学生 A は判例に比し強制処分の概念を広く解する見解を採用していることがわかる。そして、強制処分の概念を判例より広く解する学説は、事前の犯意がない者に働きかけて犯意を誘発し犯罪を実行させるのは、対象者の人格的権利・利益（憲法 13 条に由来する人格的自律権）という法益を実質的に侵害する行為なので強制処分にあたるとする。かかる見解は、おとり捜査が個人の意思決定の自由を侵害する点をとらえて強制処分とする見解であるから、おとり捜査が強制処分にあたると主張する理由となる①に入るのは、「国家の干渉を受けることなく独自に意思決定をする自由を実質的に侵害する行為である」との記述である。したがって、①にはクが入る。

② エ

学生Bは、「強制の処分」の意義について、判例の考え方を前提として、おとり捜査が強制処分にあたらない旨主張している。そして、判例（最決昭51.3.16、百選1事件）は、強制処分とは「有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味する」としている。かかる判例の考え方を前提として、おとり捜査が強制処分にあたらないと主張する理由となる②に入るのは、判例の考え方に対応した、「その相手方の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えるものではない」との記述である。したがって、②にはエが入る。

③ ウ

学生Aは、おとり捜査が任意捜査だとしても、おとり捜査を行う必要性や相当性が認められることが要件になるとし、必要性や相当性を要求する理由として、おとり捜査が、本来犯罪を防止すべき捜査機関が詐術的手段を用いて相手方に犯罪を実行させこれを検挙する捜査方法であることを挙げている。この点、おとり捜査という捜査手段は、本来犯罪を防止すべき立場にある国が犯罪を作り出すことになるのではないかと、また、捜査官において詐術的手段を用いて相手に犯罪を実行させこれを検挙するということであるため適正手続の保障や司法の廉潔性に反するのではないかとという問題点が指摘されている。そうだとすれば、本来犯罪を防止すべき捜査機関が詐術的手段を用いて相手方に犯罪を実行させこれを検挙するものというおとり捜査の性質から導かれる帰結となる③に入るのは、「捜査の公正さや廉潔性に問題があり得る」との記述である。したがって、③にはウが入る。

④ オ

学生Bは、任意捜査としてのおとり捜査にあたって、必要性や相当性を要求する理由として、④に入る根拠をあげた上、かかる根拠によれば、第三者が被害者となる殺人や窃盗等についてのおとり捜査が原則として適法とされないことの説明が容易になると主張している。そして、おとり捜査の適法性判断においては、創出される犯罪がもたらす法益侵害の性質・内容も独立して考慮要因とされるべきとする見解がある。この見解からすると、対象者や、おとり自身、さらに第三者に直接的な法益侵害が生じ得る場合、とりわけその侵害が生命・身体の安全という価値の高い法益に向けられている場合には、おとり捜査の違法性の程度は一層高まるから、おとり捜査が適法とされる余地は著しく狭くなるといえる。以上より、第三者が被害者となる殺人や窃盗等についておとり捜査が原則として適法とされないことの根拠となる④に入るのは、「捜査機関等が相手方への働き掛けによって犯罪という法益侵害又はその危険を惹起するものである」との記述である。したがって、④にはオが入る。

⑤ カ

学生Aは、おとり捜査が許される場合について、例えば、被疑者が既に大麻を所持しているという嫌疑があって、当該所持事犯の捜査の方法として行われるときに限って許されるべきと主張しているが、これは、刑事訴訟法にいう捜査が、既に行われた（あるいは現に行われつつある）犯罪について行われるものであることを根拠とする見解からの主張である。以上より、学生Aの本発言の根拠である⑤に入るのは、「刑事訴訟法の捜査は、既に行われたか又は現に行われつつある犯罪について行われるものである」との記述である。したがって、⑤にはカが入る。

⑥ ア

学生Bは、おとり捜査が許される場合について、既に犯罪が行われている場合に限られないとしているので、⑥には、時間的観点からおとり捜査という捜査方法が許される場合を緩やかに考える発言の根拠となる記述が入る。また、かかる発言は、学生Aに対する反論としてなされているところ、学生Aは刑事訴訟法の捜査の範囲からの帰結として、おとり捜査という捜査方法が許される範囲を限定している。とすると、⑥には、捜査の範囲を時間的観点から緩やかに考える旨の記述が入ることがわかる。以上より、学生Bの本発言の根拠である⑥に入るのは、「将来発生する高度の蓋然性がある犯罪について、その検挙や証拠収集を目的として捜査を行うことも許される」との記述である。したがって、⑥には、アが入る。